

行政改革试验授权制度的法理分析^{*}

杨 登 峰

摘 要：行政改革试验授权是介于立法授权与行政授权之间的一种新型授权制度，具有独立的法律地位。行政改革试验授权决定包含“暂调或者暂停部分法律的适用”和“将该决定授予特定试验主体实施”两个方面的内容。本质上，前者是法律施行力的中止和新试验法的制定两种因素的有机组合，不属于法律修改；后者是类似于行政特许的立法特别授权。作为一种公权力的行使方式，行政改革试验授权应当遵循《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》设定的程序要求，且不得逾越现代法治诸原则设定的表达形式界限和实体内容界限。

关键词：行政改革 行政改革试验 授权制度 法律中止 立法特别授权

作者杨登峰，南京师范大学法学院教授、中国法治现代化研究院研究员（南京 210023）。

引 言

行政改革试验，即行政机关就行政管理体制、机制以及管理制度、方式进行正式改革之前，先在试验区或者试点区域、试点单位进行局部试验，积累经验，待条件成熟后再在全国广泛推行，通常称“先行先试”。“先行先试”往往不仅指开改革之先河，也指“先改革后修法”。然而，“先改革后修法”与“先立法后行政”的法治原理相抵触。正因为如此，2014年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》^①（以下简称《决定》）在要求“重大改革于法有据”的同时，又要求“实践条件还不成熟、需要先行先试的，要按照法定程序作出授权”，从而将先行先试“要按照法定程序作出授权”作为我国改革试验的一项基本原则。顺应这一要求，2015年修订的《立法法》第13条规定：“全国人民代表大会及其常务委员会可以根

^{*} 本文为江苏省“333”高层次人才培养工程研究课题“我国地方实验性立法规范化研究”（BRA2015333）阶段性成果。

^① 2014年10月23日中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过。

据改革发展的需要,决定就行政管理等领域的特定事项授权在一定期限内,在部分地方暂时调整或者暂时停止适用法律的部分规定。”不过,除此之外,相关法律法规并无进一步规定。

由于法律规定比较简单,在改革试验授权实践过程中,法学界便围绕改革试验授权的法律属性、授权的合法性与正当性等问题产生了激烈争论。^① 这些问题如果不能解决,将始终困扰改革试验授权实践,也容易在理论上造成混乱。不过,回答这些问题不能就事论事,需要较为系统地解决如下几个基础理论问题:第一,行政改革试验授权在现行授权制度体系中的地位。在我国现行立法和行政法律体系中,已经确立了一系列授权制度。要厘清改革试验授权的法律属性,必须找出彼此之间的异同,厘清它与这些既有授权制度之间的关系。第二,行政改革试验授权行为的法律性质,即它属于立法行为还是行政行为;如果属于立法行为,是法律修改、废止还是其他行为;如果属于行政行为,是属于行政授权、行政许可抑或其他行为。法律行为的性质不同,所遵循的法律原则、法律程序会有所不同。第三,行政改革试验授权行为应受哪些法律原则、制度的约束。这决定着行政改革试验授权行为的界限。只有明确了行政改革试验授权行为的法律界限,才能客观评判改革试验的合法性、正当性,才能对行政改革试验授权行为施以必要的监督。

除了行政领域大量存在改革试验授权决定外,改革试验在司法、社会等其他领域也普遍存在。^② 因此,《决定》与《立法法》确立的改革试验授权制度也就不只适用于行政领域,而是适用于所有领域;上述问题也就不只是行政法学要研究的专属理论问题,而是各个部门法学都要共同研究的一个重大基础理论问题。不过,不同

① 参见范进学:《授权与解释:中国(上海)自由贸易试验区变法模式之分析》,《东方法学》2014年第2期;刘松山:《论自贸区不具有独立的法治意义及几个相关法律问题》,《政治与法律》2014年第2期;刘志刚:《暂时停止法律实施决定的正当性分析》,《苏州大学学报(法学版)》2015年第4期;彭浩:《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》,《法制与社会发展》2018年第1期。

② 行政领域的改革试验授权决定如:2014年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过的《全国人大常委会关于授权国务院在中国(广东)、中国(天津)、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定》,2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批试行期届满后有关问题的决定》。司法领域的改革试验授权决定如:2014年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件速裁程序试点工作的决定》,2016年9月3日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定》。

领域的改革试验涉及的改革事项、关涉的权力性质与权力关系不尽相同,改革试验授权所涉及的理论问题会不同,^①一个部门法学对这一问题的研究也就不能代替其他部门法学的相关研究。考虑到《立法法》关于授权的规定主要是“就行政管理等领域的特定事项”的例举式表述,改革试验授权实践中的绝大多数也属于行政管理领域,本文主要考察行政领域的改革试验授权实践,依次研究行政改革试验授权的三个基础理论问题。

一、行政改革试验授权在授权体系中的地位

授权体系是一个相对模糊的概念,可分两个层面来界定:一是法律文本或法律实践中客观存在的授权制度体系;二是法学界研究授权制度过程中建构的授权概念体系。迄今为止,学界建构的授权概念体系众说纷纭,分歧很大。^②为了避免陷入形而上的概念梳理的泥潭,本文将立足于客观的授权制度体系来进行分类分析。

(一) 我国现行法规定的授权制度体系

在规范层面,行政改革试验授权制度至少涉及立法法和行政法两个法律部门。考察行政改革试验授权制度的地位也至少应在这两个法律部门范围内进行。在现行立法法和行政法范围内,称之为授权或者冠之以授权名义的法律制度可以授权内容为标准分为立法授权和行政授权两大类。^③立法授权,即授权行为所授予的权力是立法权;行政授权,即授权行为所授予的权力属于行政权。这里的立法权仅指按照立法程序制定成文法律规范的权力,不包括广义立法权概念中的其他权能,如立法机关为行使立法权所享有的内部行政管理权;这里的行政权仅指执行法律规范的权力,不包括广义行政权概念中的其他权能,如行政机关为执行法律规范所享有的行政法规和规章制定权。

1. 立法授权的制度体系

立法授权,国内通常称为授权立法。对于立法授权,国内有学者依据授权形式

① 例如,行政改革试验授权至少涉及立法权与行政权之间的关系,而司法领域的改革试验授权至少涉及立法权与司法权的关系。授权涉及的权力种类不同,遵循的法律原理会不同。

② 授权概念的复杂性和不确定性在其他国家如美国同样存在。有学者指出:“授权概念是如此的宽泛,以致无法界定它的界限,也不能进行有效的分析。”Hannah J. Wiseman, “Delegation and Dysfunction,” 35 *Yale J. on Reg.* 233, 242-243 (2018)。

③ 我国立法学与行政法学领域已经有授权立法和行政授权两个概念。其中,授权立法主要指全国人大常委会将其立法权部分授予国务院行使;行政授权主要指法律、法规、规章给其他组织或机构授予行政权的现象。本文的立法授权与行政授权与它们相关,但不完全相同。

将其分为“以决定形式的授权”和“以法条形式的授权”两类，简称后者为法条授权。论者认为，“所谓法条授权就是指立法机关或其他有权机关在其制定的法律法规中，运用其中某一条款，将某些立法权授予有关国家机关的授权。”^① 法条授权在我国是普遍存在的，也是授予立法权的最基本方式。宪法、立法法关于立法权限的分配是这种授权方式的集中体现。除此之外，《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》关于行政处罚、行政许可和行政强制设定权的规定也是这方面的典型例子。但是，立法授权本来是作为立法权基本配置机制的例外情形来讨论的，立法授权的分类体系也应当限制在立法权基本配置机制的例外情形范围来进行，否则，势必会使分类的概念与目的发生混乱。因此，在授权方式上，立法授权应当全部都是以决定的形式进行的，不应划分出所谓的法条授权类型。

不过，在此范围内，立法授权还是可以依据授权主体及其位阶关系再分为三类：一是中央机关之间的立法授权，即全国人大及其常委会授予国务院特定的立法权。《立法法》第9条、第65条第2款等条款规定，全国人大及其常委会有权作出决定，将应由其制定法律的事项，授权给国务院根据实际需要先制定行政法规。^② 二是地方机关之间的立法授权，即享有立法权的地方人大及其常委会授予享有规章制定权的地方人民政府特定的立法权。对此，我国现行法律尚无明确规定，只能从《立法法》第82条予以解读。该条第5款规定：“应当制定地方性法规但条件尚不成熟的，因行政管理迫切需要，可以先制定地方政府规章。”但该条第6款又规定：“没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。”这种情形下，“唯一能够兼顾两者的解释方案就是在第5款所规定的特殊情形下由有权主体为地方政府授予这一权限”。^③ 三是央地机关之间的立法授权，即全国人大及其常委会授予经济特区变通性的立法权。这主要体现在《立法法》第74条和第90条第2款的如下规定中：全国人大可以授权经济特区所在地的省、市人大及其常委会制定法规，对法律、行政法规、地方性法规作出变通性规定，在经济特区范围内实施。^④

2. 行政授权的制度体系

① 陈伯礼：《授权立法研究》，北京：法律出版社，2000年，第10页。

② 该条同时规定，有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项不得授予国务院制定行政法规。

③ 赵一单：《央地两级授权立法的体系性思考》，《政治与法律》2017年第1期。

④ 除了上述三种授权立法，我国历史上还有全国人大授予其常委会一定立法权的先例。对此，有学者认为，“这些授权是在1982年宪法明确规定全国人大常委会拥有立法权之前的特定历史环境下做出的……《立法法》已将这种形式排除在我国的授权立法制度之外。”（苏元华：《立法法授权立法制度若干问题研究》，周旺生主编：《立法研究》第4卷，北京：法律出版社，2003年，第339页）

行政授权,首先可依据授权的方式分为“以立法形式的行政授权”和“以决定形式的行政授权”两类。这两类行政授权所包含的内容及其内在结构都有进一步讨论的地方。^①以立法形式的行政授权,即享有立法权的主体以立法的方式向特定主体授予行政权的法律现象。在理论与逻辑上,此类行政授权可按照授权主体和授权对象进一步划分或者界定其范围。由于我国享有立法权的主体包括特定级别的代议机关和行政机关,授权主体也就包括享有立法权的代议机关和行政机关。这里有待讨论的是授权对象。从我国立法实践看,在行政法领域,立法授予行政权的对象包括行政机关和其他主体(主要包括行政机关的内设机构、派出机构、企事业单位、社会团体等)两类,那么,以立法形式的行政授权是否也包括两类?

答案是否定的。在任何国家,行政机关是最基本的行政权力享有和行使主体。再者,行政遵循行政法定原则,行政机关享有的所有行政职权都源于法律的授予,它作出的会给人民权益造成不利影响的任何行为都必须有法上的依据。因此,与以立法形式授予立法机关立法权一样,以立法形式授予行政机关行政权是行政法的最基本形态。由于授权是用于表达基本形态之例外情形的概念,尽管在本质上给行政机关授权也是一种授权,但用授权表述这一普通现象便不太妥当。如此一来,与立法授权主要指向代议机关之外其他享有立法权的行政机关授权一样,以立法形式的行政授权实际上或者应当专指立法主体向行政机关之外的其他组织或机构授予行政权的现象。现行立法中,此种行政授权的概括性立法例是《行政诉讼法》第2条关于“法律、法规、规章授权的组织”的规定,具体性立法例如《高等教育法》第20条授予高等学校颁发学历证书权力的规定:“接受高等学历教育的学生,由所在高等学校或者经批准承担研究生教育任务的科学研究机构根据其修业年限、学业成绩等,按照国家有关规定,发给相应的学历证书或者其他学业证书。”

对于以决定形式的行政授权而言,受制于行政法定原则,在行政法上更属于特殊现象,也不多见。从现行法律实践看,此类行政授权依据授权主体可以分为两类:一是代议机关以决定形式授予行政机关特定的行政权,如《厦门市人民代表大会常务委员会关于授权厦门市人民政府为保障金砖国家领导人第九次会晤筹备和举办工

① 我国行政法学界对行政授权概念有两种意见:一是在“以立法形式的授权行政”这一层面界定的,如关保英教授认为:“行政授权是指在行政法律制度中某些行政法规范的制定机关通过法律或者法规的形式将一定范围的行政权授予行政系统以外的组织或机构行使的法律行为。”(关保英:《社会变迁中行政授权的法理基础》,《中国社会科学》2013年第10期)二是在“以决定形式的授权行政”这一层面界定的,如胡建森教授认为:“中国行政法理上的行政授权,应该指行政主体依法把自身拥有的行政权力的全部或部分转让给其他组织的行为,而不是指立法机关以立法行为设定行政权力的制度。”(胡建森:《有关中国行政法理上的行政授权问题》,《中国法学》1994年第2期)

作规定临时性行政措施的决定》。^① 二是行政机关以决定形式授予其他行政机关或者其他组织特定的行政权，如《公民出境入境管理法》（2013）第6条规定：“中国公民、外国人以及交通运输工具应当从对外开放的口岸出境入境，特殊情况下，可以从国务院或者国务院授权的部门批准的地点出境入境。”《学位条例》（2004）第8条规定：“学士学位，由国务院授权的高等学校授予；硕士学位、博士学位，由国务院授权的高等学校和科学研究机构授予。授予学位的高等学校和科学研究机构及其可以授予学位的学科名单，由国务院学位委员会提出，经国务院批准公布。”前者授予行政机关，后者授予事业单位。^② 以决定形式授予行政权的实践事例如《国家林业局关于授权森林公安机关代行行政处罚权的决定》^③ 与《审计署关于中央审计项目授权地方审计的管理办法》。^④

（二）我国现行法规定的两类授权的特征

归纳并比较上述两类授权制度可以看出，我国立法法和行政法中的授权总体上属于立法权和行政权配置的特殊形态，立法授权与行政授权虽均属授权，但有所差异。

立法授权本质上仍属于代议机关行使立法权的行为，但不属于通常的以生产法律规范为内容的立法行为，如法的制定、修改和废止等，而属于立法权行使的特殊方式。其特殊性主要体现在三个方面：第一，立法授权属于立法权力的短期转让，即立法主体将其执掌的部分立法权力在一定期限内转让给其他享有立法权的代议机关或者行政机关来行使。第二，授予的立法权既包括创制新法的权力，也包括部分中止、废止或者修改现行法的权力。从现行立法法的规定看，全国人大及其常委会给国务院的授权、省级人大及其常委会等给省级人民政府的授权应主要属于创制新法的权力。全国人大给经济特区立法机关的授权则应属于局部中止现行法和创制新法的权力。第三，立法授权的目的在于开展立法试验，是在立法条件不成熟的情形下进行的，旨在通过局部的短时的试验为正式立法积累经验、创造条件。这可从《立法法》第11条与第82条第5款的规定看出来。其中第11条规定：“授权立法事

① 2016年12月29日厦门市第十四届人民代表大会常务委员会第四十二次会议通过。

② 相关例还如《行政处罚法》第16条规定：“国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。”《测绘法》（1992）第28条规定：“违反本法规定，未经测绘资格审查违法经营测绘业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理测绘工作的部门或者其授权的部门责令停止测绘业务，没收违法所得，可以并处违法所得百分之五十至百分之百的罚款。”《野生动物保护法》（2009）第26条规定：“外国人在中国境内对国家重点保护野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像，必须经国务院野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。”

③ 1998年6月26日国家林业局第5次局长办公会议审议通过。

④ 1999年8月31日第7次审计长会议审议通过。

项,经过实践检验,制定法律的条件成熟时,由全国人民代表大会及其常务委员会及时制定法律。”这与前引第82条第5款的规定基本相同。《立法法》关于经济特区变通立法的规定虽未明确表明试验性,但经济特区本来就是为全国改革进行探索和积累经验的,其变通性立法自然以试验为内在特征。这可以从1989年3月28日在第七届全国人民代表大会第二次会议上国务院《关于提请授权深圳市人民代表大会及其常务委员会和深圳市人民政府分别制定深圳经济特区法规和深圳经济特区规章的议案的说明》得到印证。^①

行政授权的特征则要分别论说。以立法形式的行政授权,由于在形式上通过立法方式来授予其他非行政机关行政权,本质上也是在行使立法权,仍属于立法行为的范畴,只不过授权主体性质上的差异会给授权带来一些差异。经由法律和地方法规的授权应属于代议机关给其他非行政机关的授权,是狭义立法权的行使过程,属于行政职权的第一次配置,很大程度上属于行政职权的创设行为;而经由行政法规和政府规章的授权应属于行政机关给其他非行政机关的授权,虽然仍属于广义立法权的行使过程,但属于行政职权的第二次分配,很大程度上是行政机关将本应由其履行的职责向其他组织或机构的一种转移行为。在以决定形式的行政授权中,就行政机关以决定形式授予行政权而言,是行政机关行使行政职权的过程,本质上为行政行为,是行政机关将其法定职权向其他行政机关或非行政机关进行转让的二次职权配置过程。在最后一点上,与享有立法权的行政机关以立法形式授予行政权有相似之处。

在以决定形式的行政授权中,代议机关以决定形式授予行政权的特质则比较复杂,一定程度上涉及对现行法的调整适用。例如,《厦门市人民代表大会常务委员会关于授权厦门市人民政府为保障金砖国家领导人第九次会晤筹备和举办工作规定临时性行政措施的决定》虽未明确提到要调整适用的地方性法规,但其潜在的意旨是明显的。该决定指出:“在金砖国家领导人会晤筹备、举办期间及延后期限内,市人民政府针对可能存在的风险和影响,在采取常规管理措施尚不能满足保障金砖国家领导人会晤圆满顺利举办的各项要求的情况下,可以根据必要、适度原则,通过规章或者决定的形式在公共安全、社会治安、交通运输、安全生产、环境优化等领域规定临时性行政措施,并组织实施。”这里虽未明确指出要调整适用相关法律规范,

① 该说明指出:“国外一些后发展起来的新兴工业化国家的经验表明,要想在短时间内建立适应商品经济需要的法律体系,都要大胆地借鉴发达国家和地区的某些经济法规和管理体制。我们有必要吸取这一成功的经验,但这项工作十分复杂,关系重大,为稳妥起见,必须选择适当的地区进行试验,取得经验后再向全国推广。深圳市的人文地理经济情况决定了它是进行此项试验的最适当的地方。”基于这一请示,1992年7月1日,全国人民代表大会常务委员会作出了《关于授权深圳市人民代表大会及其常务委员会和深圳市人民政府分别制定法规和规章在深圳经济特区实施的决定》。

但暗含着这一意思；否则，这种授权就无意义和无必要。之所以没有明确具体的法律规范，那是因为，可能采取的临时措施涉及的法律规范较宽泛、难确定，只能概括地授予。可以看出，这种授权，所授的不仅是单纯的行政权，还有对现行法的调整适用权，介于立法授权与行政授权之间，但行政授权的色彩更浓，且具有应急性，可称其为应急性行政授权。

概括行政授权的各种形态来看，除了属于行政权的配置这一特征之外，与立法授权的根本性差别在于，这种授权具有长期性和稳定性（除了代议机关以决定形式授予行政权的个别特例），不以试验为目的，不具有试验性。面对如此丰富多彩的授权形态，现在的问题是，行政改革试验授权属于哪一种？

（三）行政改革试验授权的独立性

我国的行政改革试验授权与行政改革试验形态密切关联，因此，对我国行政改革试验授权的考察需在厘清行政改革试验形态的基础上进行。

我国的行政改革试验，依据试验场域或模式，可分为经由试验区（包括经济特区、综合改革试验区、自由贸易试验区等）的试验和经由试点的试验两类。与此相适应，我国的行政改革试验授权也主要有两类：第一，代议机关针对试验区内行政改革试验的授权。常见的有全国人大常委会授予国务院在改革试验区暂时调整实施有关法律规定的权力，如全国人大常委会于2013年8月30日作出的《关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整有关法律规定的行政审批的决定》。^①第二，代议机关针对行政改革试点的授权。常见的有全国人大常委会授予国务院在行政改革试点中暂时调整实施有关法律规定的权力，如2015年2月27日作出的《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县（市、区）行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定》。^②还有省市人大常委会授予省市人民政府在行政改革试点中暂时停止实施有关地方性法规的权力，如浙江省人大常委会于2014年12月29日作出的《关于授权省人民政府在部分市县暂时停止施行〈浙江省流动人口居住登记条例〉有关规定的决定》。^③两种授权都属于代议机

① 2013年8月30日第十二届全国人大常委会第四次会议通过。同类的还有《全国人大常委会关于授权国务院在中国（广东）、中国（天津）、中国（福建）自由贸易试验区以及中国（上海）自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定》（2014年12月28日第十二届全国人大常委会第十二次会议通过）。

② 2015年2月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过。

③ 2014年5月28日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过。该决定的主要内容是：“授权省人民政府在开展居住证制度改革试点的部分市县暂时停止施行《浙江省流动人口居住登记条例》第十五条、第十七条规定。试点市县由省人民政府确定；试点市县的居住证申领和发放管理，按照省人民政府有关规定执行。上述暂时停止施行

关以决定形式授予行政机关调整（或者停止）有关法律适用的权力。

值得说明的是，在行政改革试验实践中，并没有上级行政机关给下级行政机关授权的事例。如果行政改革试验没有触及现行法律和地方性法规的施行，则通常采用决定或者通知的形式。例如，2017年在“基层政务公开标准化规范化试点”过程中，国务院办公厅通过下发《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》^①的方式加以推行。在“行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点”过程中，国务院办公厅同样以下发《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》^②的方式加以推行。

行政改革试验授权的法律性质留在下一题来讨论，仅从外观看，它与立法授权和行政授权均不完全相同。从授权目的看，相近于立法授权，即都具有改革（或者修法）的试验性，但行政改革试验授权所授的权力不属于立法权；从授权内容看，相近于行政授权，即所授权力均为行政权，但行政授权不具有试验性。^③与行政改革试验授权最相近似的是行政授权中的“代议机关以决定形式授予特定行政机关特定行政权”的授权形态，两者的授权主体、授权对象、授权方式都是相同的，而且所授权力中都具有暂时调整有关法律法规适用的内容，但还是有一定区别，即代议机关以决定形式的行政授权只是解决特别时期特别问题的特别手段，并不以改革试验为目的。

由上可见，我国行政改革试验授权虽然兼具现行立法法和行政法中的立法授权与行政授权的一些特点，但又不完全相同，不能简单将其与传统的立法授权或行政授权等而同之，应将其作为独立于这两类授权的新制度来看待和研究。

二、行政改革试验授权行为的法律属性

上文就行政改革试验授权的特质作了初步讨论，但要真正揭示行政改革试验授权制度的特殊性，还需要客观界定它的法律属性。就这一问题，自中国（上海）自由贸易试验区设立之初全国人大常委会给国务院作出授权决定以来，学界就开始了

在一年内试行。”类似的还如杭州市人民代表大会常务委员会《关于授权市人民政府在滨江区暂时停止施行〈杭州市流动人口服务管理条例〉有关规定的决定》（2014年12月30日杭州市第十二届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，2015年3月27日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准）。

① 国办发〔2017〕42号。

② 国办发〔2017〕14号。

③ 对立法授权与改革试验授权之间的区别，有学者作过一些简单比较，可参见彭浩：《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》，《法制与社会发展》2018年第1期。

持续讨论，其中有法律修改论和非法律修改论两种对立观点。

（一）改革试验授权行为的法律修改论及其不当

法律修改论者认为，法律修改的基本含义是指国家立法机关依照法定程序对现行法律的某些部分加以变更、删除或者补充的立法活动，^①而改革试验授权决定“暂时调整或者暂时停止适用法律”就意味着被调整或者停止适用的个别法律条款在一定期限内特定区域不再发生效力，或者是对原有的适用条件作出了某些变更。就全国人大常委会针对上海自贸区给国务院的授权决定而言，其实是将《外资企业法》、《中外合资经营企业法》和《中外合作经营企业法》规定的企业设立的行政审批制改为备案登记制，降低了外资进入中国市场的条件。因此，“这显然是对三部法律相关条款的变更，属于法律的修改。”“只是这种修改是附加条件的修改，即‘上述行政审批的调整在三年内试行，对实践证明可行的，应当修改完善有关法律；对实践证明不宜调整的，恢复施行有关法律规定’。”^②

对法律修改论，学界提出了诸多不同意见。反对理由主要有两点：第一，改革试验授权决定不符合法律修改的形式。他们认为，我国修改法律主要采用修订、修改决定、修正案三种形式。但全国人大常委会作出的授权决定，对暂时调整的原法律文本并未作任何实质性修改，依然保持先前的原貌。这与法律修改的常规做法不一致。第二，改革试验授权决定不产生法律修改的效力。他们认为，如果授权决定在性质上属于法律修改，则一经作出，即产生法律效力，被调整的法律将永远停止实施。但从全国人大常委会所作授权决定的内容来看，相关法律停止实施却是暂时的。如对上海自贸区的授权决定授予的调整期为三年，实践证明不宜调整的，要恢复施行有关法律规定。论者还反证性地指出，如果改革试验授权决定属于法律修改，则改革试验授权决定实施之后，如果试验成功，就不应再作出相应的法律修改决定，否则就自相矛盾。但实际并非如此。例如，全国人大常委会在给相关自由贸易试验区作出调整适用相关法律法规的授权决定后，恰恰又作出了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国外资企业法〉等四部法律的决定》。这就说明，作为改革试验授权主体的全国人大常委会自己也不认为授权决定属于法律修改。^③

应该说上述否定意见值得肯定，特别是从法律效果角度的论证，但理据还不够

① 黄文艺：《立法学》，北京：高等教育出版社，2008年，第91页。

② 范进学：《授权与解释：中国（上海）自由贸易试验区变法模式之分析》，《东方法学》2014年第2期；类似观点还可参见刘松山：《论自贸区不具有独立的法治意义及几个相关法律问题》，《政治与法律》2014年第2期。

③ 参见刘志刚：《暂时停止法律实施决定的正当性分析》，《苏州大学学报》（法学版）2015年第4期；彭浩：《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》，《法制与社会发展》2018年第1期。

清晰透彻。法律修改会引起一部法律部分条款效力的变动，但法律部分条款效力的变动并不一定构成法律修改。法律修改其实是由法律废止和法律创制两个核心要素有机组成的。法律废止意味着一个法律规范自废止之日不再对其适用对象发生约束力。法律创制意味着一个新法律规范被制定出来并发生约束力。在立法实践中，法律废止和法律创制是两个不同的立法行为，可分别进行。但在法律修改过程中，两个行为必须紧密结合在一起，即在废止一个法律规范的同时，与其事实构成要件相同的另一个法律规范必须同时被创制出来并得到施行，在适用对象与适用时间上实现无缝对接。否则，就不构成法律修改，而是两个不同的立法行为。就改革试验授权决定而言，它的确在一定程度上创制了一个法律规范，且该规范在授权决定施行之日开始施行，但它仅暂时停止适用了相关法律规范，并没有废止该法律规范。如果试验不成功，改革不推行，则该法律规范还要恢复施行。与此同时，所创制的新法律规范要废止。因此，认为暂时调整或者暂时停止部分法律的适用不属于法律修改的观点是正确的。

其实，法律修改论者也自感其观点不能完全自圆其说，于是，在主张法律修改的同时，又主张是附条件的法律修改，或者主张是特殊的法律修改。^①但问题是，如果行政改革试验授权行为不属于法律修改，那属于什么呢？对此，否定法律修改论者却没有拿出令人满意的意见，有些论者避而不谈，有些论者则认为，“授权地方改革试点决定并非是法律修改，而是法律修改的‘试验模式’。”^②这种看法显然自相矛盾。可见，不论是法律修改论还是其否定意见，均没有完成说明改革试验授权行为法律性质的任务。

（二）“暂时调整或者停止适用法律”的立法施行力中止性

分析行政改革试验授权决定的法律属性，必须将其与授权决定内容的性质区分开来。上述论者之所以界说不清，另一个根源在于他们将二者混淆在了一起，实际是在界定暂时调整或者暂时停止适用法律的性质。但在界定这一性质时，没有深入分析立法行为的效力，一些基本问题没有厘清，而这又源于立法学没有建构立法行为的效力体系理论。

立法行为属于一种公权力行为，与行政行为具有共同性，因此，立法行为的效力可以比照行政行为的效力来分析。行政行为的效力是多元的和分层次的。这里值得关注的有拘束力、执行力和存续力。拘束力系指行政相对人和利害关系人必须对行政行为予以必要的尊重和服从。执行力系指行政相对人应当立即执行行政行为所

① 参见刘松山：《论自贸区不具有独立的法治意义及几个相关法律问题》，《政治与法律》2014 年第 2 期。

② 彭浩：《授权地方改革试点决定的性质与功能探析》，《法制与社会发展》2018 年第 1 期。

设定的义务。存续力则系指做出该行政行为的行政主体不得随意废止或者变更其作出的行政行为。这些效力既非同时发生，也非同时消灭。对于一般的行政行为来说，存续力从行政行为成立时发生，拘束力、执行力从行政行为生效时发生。如果行政行为附施行期限或者条件，则执行力从所附施行期限届满或者条件成就时发生。行政行为生效后，其效力会随着法律、时事以及利害关系人状况的变化而变化，从而有行政行为效力的变更、废止、中止和终结。行政行为效力的变更与废止，即因行政行为所依据的法律、法规、规章的修改、废止，或者行政行为所依据的客观事实发生重大变化，部分地调整行政行为的内容或者终止行政行为的全部效力。行政行为的中止与终结则是在不停止其他效力的前提下，仅在一定期限内或者条件下中止或终结行政行为的执行力，其他效力不受影响，其主要表现是行政强制执行的中止与终结制度。^①

比较立法行为可以看出，立法行为的效力是多元的。立法行为首先应当具有公定力（类似于行政行为的拘束力但约束性更强）和执行力（相当于行政行为的执行力），各种社会主体——不论是私权利主体还是公权力主体，都必须对立法予以充分的尊重和服从，必须严格执行法律、法规和规章的规定。立法行为还应当具有确定力（相当于行政行为的存续力但稳定性更强），立法主体制定法律之后，不得朝令夕改。确定力源于法的稳定性，富勒称其为“法律在时间支流中的连续性”。^② 与此同时还可以看出，立法行为各种效力的发生也是可以分步的。一部法律文件通常要经过人大投票表决通过、国家主席签发并予以公布、付诸实施等阶段。一部行政法规通常要经过国务院常务会议表决通过、国务院总理签发并予以公布、付诸实施等阶段。这些阶段可能在同一时点发生，也可能在不同时点发生。^③ 在不同时点发生时，立法的确定力、公定力和执行力便必然分离。确定力应当从全国人大常委会表决通过时发生，公定力和执行力一般情况下应从主席签发主席令予以公布时发生。如果法律规定了过渡期，则执行力须从过渡期届满之日发生。无论如何都不能认为，立法的所有效力在过渡期满时才发生，人大表决通过、国家主席签发公布的法律文件没有任何效力，或者说国务院常务会议讨论通过、国务院总理签发公布的行政法规

① 相关论述参见杨登峰：《行政决定效力的本质与体系》，《行政法学研究》2013年第4期；哈特穆特·毛雷尔：《行政法学总论》，高家伟译，北京：法律出版社，2000年，第266—269页；盐野宏：《行政法》，杨建顺译，北京：法律出版社，1999年，第100—112页；翁岳生编：《行政法》上册，北京：中国法制出版社，2002年，第677—691页；叶必丰：《行政行为原理》，北京：商务出版社，2014年，第278—292页。

② 富勒：《法律的道德性》，郑戈译，北京：商务印书馆，2005年，第94—96页。

③ 例如，《政府信息公开条例》经2007年1月17日国务院第165次常务会议通过，2007年4月5日国务院令492号公布，自2008年5月1日起施行。《行政强制法》由2011年6月30日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2011年6月30日中华人民共和国主席令第49号公布，自2012年1月1日起施行。

没有任何效力。

既然立法行为的效力是多元的,不同效力的发生是可以分步的,则其效力的变动或者消灭也就可以分阶段或者分层次进行。目前的立法实践实际上也是这样运作的。法律修改就其本质而言应属于立法行为效力的部分消灭,而法律废止则属于立法行为效力的全部消灭。但遗憾的是,我国以前的立法实践忽视了法律施行中止制度的确立。所谓法律施行中止制度,也可称为立法行为效力中止制度,即在保留立法的确定力、公定力及绝大部分条款施行力的同时,在有限时间和地域暂停部分条款的施行力。对此,学界也缺乏必要的研究和探讨。正因为这样,当《立法法》第13条规定可授权“在部分地方暂时调整或者暂时停止适用法律的部分规定”以及在行政改革试验授权决定中包含“暂时调整或者停止适用法律的部分规定”时,惯于对号入座的法学工作者便不知所措。但从本质看,在试验期间暂时调整或者停止适用法律的部分规定就是法律施行力的中止。

不过,仔细分析,“暂时调整法律的部分规定”与“暂时停止适用法律的部分规定”还是有所区别。前者包括但不限于暂时停止适用。从实践看,行政改革试验授权决定的内容往往不仅包括暂时停止相关法律法规的适用,同时还包括暂时创制和施行一些新的法律规范。例如,《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在北京市大兴区等三十三个试点县(市、区)行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定》在暂时停止实施集体建设用地使用权不得出让等规定的同时,允许在符合规划、用途管制和依法取得的前提下将存量农村集体经营性建设用地使用权予以出让、租赁、入股,实行与国有建设用地使用权同等入市、同权同价;在暂时停止实施宅基地审批权限规定的同时,将使用存量建设用地的审批权下放至乡(镇)人民政府,将使用新增建设用地的审批权下放至县级人民政府。在这里,暂时停止适用法律属于立法施行力的中止,但暂时创制并施行新的法律则不能归为立法施行力的中止,而应当属于与试行法或者暂行法相似的新型试验立法。^①可以说,正是旧法施行效力的中止与新试验立法的创制和施行,构成了行政改革试验的有机链条。

(三) 改革试验授权属于类似特许的特别授权

对我国行政改革试验授权实践的考察表明,具体暂时调整或暂停适用哪些法律以及如何调整,在授权决定中已经作了非常明确的规定。换言之,暂时调整或者暂停适用哪些法律以及如何调整是由授权主体自己决定和完成的,并没有授予给试验主体,所授予的只是实施“暂时调整或暂停适用部分法律的决定”的特别权力。那么,行政改革试验授权决定的性质到底是什么?本文观点是,它属于类似于行政特

^① 关于试验立法的论述参见杨登峰:《我国试验立法的本位回归:以试行法和暂行法为考察对象》,《法商研究》2017年第6期。

许的特别授权。

与立法学没有立法行为的施力力及其中止等概念一样,立法学中尚没有类似于行政特许的“立法特别授权”这样的表述。因此,还需借助行政法学中的行政特许概念及其理论来阐述。行政特许,又称政府特许,是行政许可的一种,与普通许可相对,是以有无赋予许可相对人某种特别权力为标准对行政许可所作的划分。相应地,行政特许也就是赋予相对人特定自然资源、公共资源开发使用权或者直接涉及公共利益的特定行业排他性经营权的行为,如烟草专卖许可等。而普通许可则只是对符合法定条件的相对人解除法律禁止、准予从事特定活动的行为,不赋予对方任何特别权力,如机动车驾驶许可等。

行政特许有诸多特点,但值得本文关注和强调的主要有三点:第一,行政特许以申请为前提。与依职权的行政行为(如行政处罚、行政征收、行政强制)不同,行政特许都以相对人的申请为前提。这是所有行政许可共同的基本特征。第二,特许效果具有赋权性,即从行政特许的效果看,它使“受特许人取得了原本不具有的自然资源及公共资源的使用权或特定行业的排他性经营权”。第三,特许数量有限,特许权利具有独占性。在特许涉及的不少领域,由于资源稀缺性和资源分配数量的有限性,行政特许的数量是有限的,一旦“针对某一组织或个人作出特许后其他组织或个人就无法再获得特许”。^①其结果,由此取得的行政特许权利也便具有独占性和排他性。

将上述行政特许的特征与行政改革试验授权加以比较,会发现二者在本质上有共同之处:第一,行政改革试验授权都是依申请作出的。考察行政改革试验授权实践可以发现,不论全国人大常委会的授权还是地方人大常委会的授权,都是以行政机关的授权申请为前提的。例如,在药品上市许可持有人制度改革试点授权过程中,先是国务院作出《关于授权国务院开展药品上市许可持有人制度试点和药品注册分类改革试点工作的决定(草案)》(以下简称《决定(草案)》),并提请全国人大常委会审议。在此基础上,全国人大常委会才作出《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关问题的决定》。^②这里的《决定(草案)》实际相当于特别许可的申请。第二,行政改革试验

① 王克稳:《行政许可中特许权的物权属性与制度构建研究》,北京:法律出版社,2015年,第22、33页。

② 参见2015年10月30日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议上国家食品药品监督管理总局局长毕井泉所作的《关于〈关于授权国务院开展药品上市许可持有人制度试点和药品注册分类改革试点工作的决定(草案)〉的说明》,以及2015年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关问题的决定》。

授权决定赋予改革试验主体实施暂时调整或者暂停适用部分法律决定的特别权力。例如,在药品上市许可持有人制度试点授权决定中,其实授予试点单位按照决定调整《药品管理法》相关规定的特别权力,^①以组织开展药品注册分类改革,提升药品质量,推进我国药品产业转型升级。第三,行政改革试验授权的试验主体是有限的。每一次行政改革试验授权,都是局限于一定单位或者区域的,数量屈指可数。再就药品上市许可持有人制度试点而言,仅授权国务院在北京、天津、河北、江苏等十个省、直辖市开展药品上市许可持有人制度改革试点。授权之外的其他省市没有进行同样改革试验的权力。

基于上述共同点,可以说,行政改革试验授权与行政特许具有很大相似性。当然,不得不承认,这种授权还是不同于行政特许。行政特许是行政机关作出的,特许的对象是私法主体,特许的目的在于保证自然资源、公共资源的有序开发和涉及公共利益的特定行业的有序经营,许可相对人取得的是开发资源或者从事特定行业的经营权,这种经营权属于一种私法权利;而行政改革试验授权是立法机关作出的,授权对象是行政机关,其目的在于将实施暂时调整或者暂停适用部分法律规定之决定的权力赋予特定的行政主体,使改革得以稳步、有序地进行,且这种适用权属于一种行政公权力。因此,只能认为二者相似,不能说相同;不能认为是特许,仍要定性为授权。从授权的角度看,是代议机关以决定的形式给行政机关授予特别行政权的过程,依然属于行政授权的范畴。在没有更好的法理论证结论之前,可暂且将其表述为“试验性行政授权”,以别于前文所述的“应急性行政授权”。

三、行政改革试验授权应恪守的法律界限

在法治国家背景下,基于分权原则,一个国家机关不得侵占另一个国家机关的职权,也不得将自己执掌的职权转让给其他国家机关,从而原则上既禁止越权也禁止授权;即便在一定情形下允许一定范围的授权,也要受制于法的约束。^②我国的行政改革试验授权既是一种授权,也属于公权力行使的一种方式,自然也应受到法的约束,止于法律设定的界限。由于行政改革试验授权行为包含行为的作出程序、

① 这次改革把新药由现行的“未曾在中国境内上市销售的药品”调整为“未在中国境内外上市销售的药品”。在国外已经上市而在国内尚未上市的药品,已不再属于新药的范围,将按仿制药审批。考虑到这类药品没有国家标准,试点方案将“仿已有国家标准的药品”调整为“仿与原研药品质量和疗效一致的药品”。这一改革提高了仿制药上市审批标准。

② Ronald A. Cass, “Delegation Reconsidered: A Delegation Doctrine for the Modern Administrative State,” 40 *Harv. J. L. & Pub. Pol’y* 147 (2017); Hannah J. Wiseman, “Delegation and Dysfunction,” 35 *Yale J. on Reg.* 233, 242-247 (2018).

行为的表达形式和行为的实体内容三个方面的要素，法律对于它的要求便可从这三个方面来分析，它的作出也就受限于法律就这三个方面所提出的要求。

（一）行政改革试验授权行为的程序要求

程序法治是现代法治的基本要求之一。对于行政改革试验授权行为的程序，《决定》明确要求“要按照法定程序作出”。但遗憾的是，我国现行法律法规并没有规定关于行政改革试验授权的专用程序。这种情形下，正确解释和理解行政改革试验授权的“法定程序”便成为改革试验授权的理论研究任务，且只能通过探求可资类推适用的程序来实现。

前文已表明，行政改革试验授权决定其实包含两个方面的要素：一是暂时调整或暂停适用部分法律的决定；二是将暂时调整或暂停适用部分法律之决定授予特定对象予以实施的决定。二者虽在一个行为（决定）中完成，但性质有一定区别：前者属于对法律效力的中止与新试验法的制定，是授权决定的实体内容；后者属于一种特殊的行政授权，是授权决定的外在形态。因此，行政改革试验授权程序的核心是暂时调整或者暂停适用部分法律的程序。授权决定本身应该只是一个意思表达行为，与其他立法授权和行政授权不应有质的区别。暂停法律的施行力虽然是暂时的和局部的，但仍然属于对现行法律秩序的改变。新试验法虽然也是暂时的和局部的，但仍然属于新法律规范的制定。两者的结合实际上构成了一种类似于法律修改的法律预变动链条。这也正是有些学者牵强地称其为法律修改的根源所在。这样，在法律没有专门规定法律中止和试验立法制度，学界也缺乏相关研究的情况下，不妨类比法律修改、法律废止的制度来解决这一问题。

对法律修改权限和程序，《立法法》第7条规定：全国人大修改基本法律；全国人大常委会修改除基本法律以外的其他法律；在全国人大闭会期间，对全国人大制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。第59条规定，法律的修改和废止程序，适用《立法法》对立法程序的规定。不过，第30条对于法律修改程序也作了一些较为宽松的规定：“部分修改的法律案，各方面的意见比较一致的，也可以经一次常务委员会会议审议即交付表决。”这些规定基本确定了法律修改、废止的主体及其权限和程序。对于地方性法规的修改和废止程序，目前在《立法法》和《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》中虽无规定，但一些地方立法作了类似于法律修改、废止程序的规定。例如，《北京市制定地方性法规条例》^①第3条第3款规定，在市人大闭会期间，市人大常委会可以对市人大制

^① 2001年2月10日北京市第十一届人民代表大会第四次会议通过，2002年3月29日北京市第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议修订，2017年1月20日北京市第十四届人民代表大会第五次会议修订。

定的法规进行部分补充和修改,但是不得同该法规的基本原则相抵触。第54条规定,法规的修改和废止程序,适用北京市人大及其常委会的一般立法程序。第36条规定:“列入常务委员会会议议程的法议案,一般应当经三次常务委员会会议审议后再交付表决……部分修改的法议案,各方面的意见比较一致的,也可以经一次常务委员会会议审议即交付表决。”从这些规定看,我国法律和地方性法规的修改与废止基本遵循“谁立法谁修改”和“修法程序与立法程序基本趋同”的原则。

基于暂时调整或暂停部分法律的适用与法律废止、修改对于法律秩序影响的相似性,则行政改革试验授权的法定权限和程序应当是:试验内容涉及法律的暂时调整或者暂停适用的,由全国人大及其常委会授权;授权程序遵循法律的制定程序;各方面意见比较一致的,可以经一次常委会会议审议即交付表决。试验内容涉及地方性法规的暂时调整或者暂停适用的,由相应的地方人大及其常委会授权;授权程序遵循地方性法规的制定程序;各方面意见比较一致的,也可经一次常委会会议审议即交付表决。实际上,目前我国行政改革试验授权基本上是按照上述程序进行的。例如,《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在北京市大兴区等232个试点县(市、区)、天津市蓟县等59个试点县(市、区)行政区域分别暂时调整实施有关法律规定的决定》和《浙江省人大常委会关于授权省人民政府在部分市县暂时停止施行〈浙江省流动人口居住登记条例〉有关规定的决定》,前者经第十二届全国人大常委会第十八次会议审议通过,后者经浙江省第十二届人大常委会第十次会议审议通过。^①

有待进一步讨论的是,行政改革试验授权决定是否要由国家主席签署主席令予以公告。按照《立法法》第25条和第44条的规定,全国人大及其常委会通过的法律须由国家主席签署主席令予以公布。这里虽然没有明确要求法律修改要由国家主席签署主席令予以公布,但从第25条和第44条在《立法法》中的序位看,它既是立法程序的最后一个环节,也是对法律制定和修改的总体要求,法律修改从而须遵循这一程序要求。从我国立法实践看,法律修改决定实际上也是由国家主席签发主

① “农村集体所有耕地和宅基地使用权抵押制度改革试点”,由于涉及突破物权法、担保法的相关规定,2015年10月,人民银行会签中央农办、发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、农业部等部门,向国务院报送了《关于授权国务院在北京市大兴区等全国278个县(市、区)行政区域暂时调整实施有关法律规定的决定(草案代拟稿)》及说明的请示。国务院法制办在调查研究的基础上,对代拟稿作了修改完善,形成了《关于授权国务院在北京市大兴区等232个试点县(市、区)、天津市蓟县等59个试点县(市、区)行政区域分别暂时调整实施有关法律规定的决定(草案)》。草案经2015年12月2日国务院第114次常务会议讨论通过,于2015年12月21日提交第十二届全国人大常委会第十八次会议审议。其间,人大常委会进行了分组审议,并经法律委员会修改,最后于2015年12月27日经第十二届全国人大常委会第十八次会议审议通过。这一程序与法律修改程序没有多大差别。

席令予以公布的。例如,《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》于2017年6月27日由国家主席令第70号公布。前文论述表明,在没有试验授权专用程序的情形下,行政改革试验授权程序可以比照适用法律修改的程序,实际上也是比照适用该程序的。但是,在行政改革试验授权实践中,并没有由国家主席签署主席令予以公布的先例。其中原理有待释明。

代议机关通过的法律由国家元首签署公布是多数国家的普遍做法,但不同国家赋予它的功能与意义不同。有些国家元首签署公布法律的权力具有实质意义,可以利用公布权制约立法权,可以通过不签署要求国会重新审议。有些国家元首签署公布法律的权力仅具象征意义,签署公布纯属立法过程中的一道程序,旨在透过国家元首的权威和尊严体现法律的权威和尊严。基于我国人民代表大会制度的特点,国家主席签署主席令公布法律的权力应该属于后者。^①由此可见,涉及国家法律的制定和修改等重大事件需通过国家主席签署主席令公布以体现其权威和尊严,但也只有涉及国家法律的制定和修改这类重大的事件才可以由国家主席签署主席令公布。相比之下,行政改革试验授权决定仅涉及法律施行力的局部中止和新试验法的局部创制,修改与否还不确定,其影响力和重要性均小于法律修改,自然无须国家主席签署主席令公布。这应是行政改革试验授权程序明显不同于法律修改程序之处。

(二) 行政改革试验授权行为的形式要求

行政改革试验授权的形式要求,系指现代法治对于行政改革试验授权决定在形式结构和语言表达方面的要求。形式结构,即授权决定的形式要素及其组合序位。从实践看,我国行政改革试验授权决定已形成较为固定的形式结构,一般包括标题、授权时间、授权目的、授权内容、授权期限和施行时间等要素。其中,标题包括授权主体、授权对象和授权事项,授权时间表明授权决定通过的程序及日期,并以括注形式附于标题之下。授权内容如果较多,可以附件形式予以详细补充说明。施行时间根据需要可始于授权时间,也可设定一定的过渡期。总体看,实践中的问题不大。这里需要重点讨论的是语言表达要求。语言或者文字是绝大多数法律行为意思表达的载体,是现代法治聚焦的基本对象之一。对法律语言或者文字表达,现代法治已经提出了明确性原则,需进一步阐明的是该原则对于行政改革试验授权行为的可适用性及其提出的基本要求。

根据人民民主、人权保障、法治以及法律保留等原则,但凡涉及国家与人民的重大事务,或者减损人民的权益以及增加人民的义务,必须由代议机关以立法的形

^① 有学者指出:“国家主席公布法律有利于体现国家元首的权威和尊严,也有利于体现和维护社会主义法制的权威和尊严。”(李培传:《论立法》,北京:中国法制出版社,2013年,第205页)

式加以规定。相应地,没有代议机关的法律规定,行政机关不得对国家与人民的重大事务作出决定,也不得自行减损人民的权益或者增加人民的义务。但是,欲使这些要求真正落到实处,就必须进一步要求代议机关亲自制定法律,且制定的法律应当清晰明确;如果代议机关不得已立法授权,则授权事项必须有限,授权内容必须清晰明确。反之,如果法律语义含糊不清,立法授权没有边际或者授权内容模糊不清,则行政机关要么不知所措,要么无所不为,从而人民权益面临风险,通过法律制约行政权的目的受损。正因为如此,二战后不久,德国法学者舒菲力兹教授就提出:“法律必须在立法条文内明白让法律的适用者——人民、行政及司法权力者,知道其合法权限所在,藉以界定一个清楚的权利义务范围。”同时,“立法在字义上必须极为明白、单纯,不会有含糊不清,同时与其他法律之间的关系亦必须由立法者加以澄清。易言之,立法者有义务负责提出第一流法律的语义品质。”^①也正因为如此,战后德国《联邦基本法》第80条第1款规定:“法律可授权联邦政府、联邦部长或各州政府发布具有法律效力的命令。这种法律应当规定该授权的内容、目的和范围。”

明确性原则的适用不以宪法明文规定为要件。二战以来,即便宪法中没有规定,明确性原则在西方法治国家也得到普遍应用。美国应用明确性原则的判例较多,^②其中在1972年的Papachristou v. City of Jacksonville案中,联邦最高法院认为,待决法律语义过于模糊,未能合理地告知一个正常心智的人何种行为是法律所禁止的,遂认定无效。^③欧洲人权法院在“The Sunday Times v. United Kingdom”一案中指出,法律必须是明确和可了解的,公民必须能够从法律中得到充分确定的指示。此外,本案法院还指出,除非在制定时具备足够的精确性,使公民能够调整他的行为,合理预见其行为的后果,否则就不能称其为法律。^④明确性原则在这些国家得到普遍应用的原因在于,它是从民主、人权保障、法治以及法律保留等宪法原则推导而来的,只要承认这些宪法原则,就必然要承认明确性原则并发挥这一原则的保障功能。在我国,民主、人权保障、法治和法律保留等已经成为宪法和立法法明确规定

① H. Schulze-Fielitz, Rdnr. 116. 转引自陈新民:《德国公法学基础理论》下册,济南:山东人民出版社,2001年,第547—548页。

② Russell L. Weaver et al., *Constitutional Law*, New York: Aspen Publishers, 2009, pp. 332-335.

③ 参见Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); Board of Airport Commissioners v. Jews for Jesus, Inc., 482 U.S. 569 (1987); Graned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Russell L. Weaver et al., *Constitutional Law*, pp. 332-335.

④ The Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 26 April 1979, Series A, No. 30; (1979-80) 2 HERR 245. 另参见克莱尔·奥维·罗宾·怀特:《欧洲人权法:原则与判例》,何志鹏、孙璐译,北京:北京大学出版社,2006年,第277—278页。

或者体现的原则，基于同样的道理，虽然宪法没有规定明确性原则，但它应当是宪法上民主、人权保障、法治等原则的题中之义。^① 其实，我国《立法法》第10条对授权明确性已经作了规定：“授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限以及被授权机关实施授权决定应当遵循的原则等。”换言之，授权明确性已经成为我国立法上的一项基本原则。

对于行政改革试验授权行为而言，它属于立法机关针对特定对象作出的具体行为，与行政法上的具体行政行为具有相似性。比之于一般立法和立法授权行为，行政改革试验授权行为更需要表达的明确性，也更容易做到表达的明确性。如果立法和立法授权须遵守明确性原则的话，则行政改革试验授权不仅不能例外，还应更进一步。这与行政行为、司法行为的明确性相似。将明确性原则适用于行政改革试验授权行为意味着：第一，授权决定的文字表达要符合语法规则和逻辑规范，尽量使用法律专业语言而非日常生活用语；第二，对于要中止的法律条文和拟试验的新法律制度要作具体明确的规定，不用或尽量少用“等”或者“其他”等不确定法律概念；第三，对试验单位、试验区域要作正面列举，试验期限要明确。

考察我国行政改革试验授权实践可以发现，明确性原则其实已经得到遵循或者体现。例如，全国人大常委会讨论授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区内暂时停止实施有关法律规定的过程中，“有些常委会组成人员提出，按照立法法的有关规定，授权的范围必须明确，建议删去决定草案中的‘等国务院决定的试验区’。还有委员提出，负面清单的含义不清楚，建议用法律语言予以明确。”全国人大法律委员会与国务院法制办公室经研究决定，“建议明确界定中国（上海）自由贸易试验区的范围，删去决定草案中的‘等国务院决定的试验区’，并将‘负面清单’表述为‘国家规定实施准入特别管理措施’。”^② 这符合行政改革试验授权明确性原则的要求，应当在所有行政改革试验授权实践中加以体现和遵循。

（三）行政改革试验授权行为的内容要求

行政改革试验授权行为是授权主体行使授予权作出的授权决定。这一决定内涵两个层面的实体内容：一是授权主体授予权的行使；二是授权主体设定的试验方案。授予权的行使是隐性的和内在的，但却是授权决定的基础和依据。就如同行政许可

① 明确性原则已得到我国学界研究和认可，如欧爱民：《法律明确性原则宪法适用的技术方案》，《法制与社会发展》2008年第1期；韩永红：《法明确性原则与宪法关系的研究》，北京：法律出版社，2013年；胡建森主编：《论公法原则》，杭州：浙江大学出版社，2005年；等等。

② 2013年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议上《全国人民代表大会法律委员会对〈关于授权国务院在中国（上海）自由贸易试验区等国务院决定的试验区内暂时停止实施有关法律规定的决定（草案）〉审议结果的报告》。

行为一样,许可主体的许可权虽然在行政许可决定中看不见摸不着,却是行政许可决定的权威和效力根源。基于此,则法治对于行政改革试验授权行为实体内容的要求可从两个方面来分析。

对于授予权的行使而言,基于公权力法定与禁止越权原则,基本的法律要求是,授权主体必须在其法定权限范围内行使授予权。对于行政改革试验授权的权限,立法法并未直接规定,但是,不论是立法授权还是行政授权,授权主体只能将自己享有的权力授予其他主体,不能也无法授予其他主体自己不享有的权力,此为公理。因此,行政改革试验授权主体的授予权应当等于甚或小于其享有的立法权限。这里涉及的相对复杂的问题是,如果改革试验方案涉及暂时调整或者暂停全国人大制定的基本法律的部分条款,而改革试验授权决定由全国人大常委会作出的话,其授予权的权限该如何划定。

这里可以比照基本法律的修改权。按照《立法法》第7条的规定,基本法律的制定和修改权属于全国人大,但在全国人大闭会期间,全国人大常委会可以对全国人大制定的基本法律进行部分补充和修改,只是不得同该法律的基本原则相抵触。如前所述,法律修改对于现行法律秩序的影响远大于改革试验过程中对于法律的暂时调整或者暂停适用。既然全国人大常委会修改基本法律时仅以“不得同该法律的基本原则相抵触”为原则,则在其作出此类行政改革试验授权决定时恪守“不与基本法律的基本原则相抵触”的原则就应该符合法治的基本要求了。对于地方行政改革试验授权来说,尽管地方人大与其常委会之间的立法权限划分不是很清晰,但解决这一问题的原理应当相同。

对于授权主体设定的试验方案,可以从授权的裁量性来分析。试验方案所表达的主要是试验与否以及如何试验的意见。其中,试验与否的问题涉及的是改革试验的先决条件;如何试验的问题涉及的是改革试验的主体、区域与期限。关于试验的先决条件,《立法法》第13条仅规定“根据改革发展的需要”,《决定》仅规定“实践条件还不成熟”;关于试验方案,《立法法》第13条仅规定“在一定期限内部分地方”。因此,试验条件的判断与试验方案的制定都是裁量性的,行政改革试验授予权也因此属于一种裁量权。

考虑到行政改革试验的多样性和复杂性,赋予改革试验授权主体以裁量权是适当的,但这种权力同样应当受到规范和制约。对于裁量权的制约和规范,现代法治提供有程序的制度(如公开、公众参与)和实体的制度(如裁量基准、法律原则)。^①程序的制约机制其实已在“授权的程序要求”部分中得到体现。裁量基准主

① 肯尼斯·卡尔普·戴维斯:《裁量正义》,毕洪海译,北京:商务印书馆,2009年,第108—113页;田村悦一:《自由裁量及其界限》,李哲范译,北京:中国政法大学出版社,2016年,第140—145页。

要是行政法的机制,制定立法裁量基准的可行性还有待研究。因此,这里值得讨论的是裁量权行使应遵循的基本原则及其对行政改革试验授权提出的要求。在公法领域,制约和规范裁量权的法律原则主要有平等原则、发端于英国的合理原则和发端于德国的比例原则。^① 平等原则要求,“相同的同等对待,不同的区别对待”;英国的合理原则要求,“裁量权的行使应当以法律目的为目的,必须全面考虑该当考虑的相关因素,必须将不相关因素排除在考虑范围之外”;^② 德国的比例原则则要求,裁量行为要具有目的正当性、效果适当性、侵害最小性和成效均衡性。^③ 这些原则对于立法权和行政权有普遍约束力,对于行政改革试验授权行为应当具有一定适用性。

借鉴上述原则,规范行政改革试验裁量权,首先,要考虑改革试验目的的复杂性。改革试验可能为了推动改革而进行,也可能为了放慢改革步伐而进行;有可能为了全民福利而进行,也可能为了调整局部利益而进行。其次,要考虑改革方案的可试性。有些改革可以通过试验验证改革的可行性和科学性,有些改革则不可能通过试验检验其可行性和科学性。再次,要考虑我国不同地方政治、地理、经济和文化的差异性。有些地方很先进,有些地方很落后。这种差异意味着,改革试验主体、区域和期限的选择和设定要具有代表性。最后,要考虑改革试验的成本与效益。综合考虑这些因素,则行政改革试验的方案应符合以下要求:第一,行政改革试验及其授权必须有正当目的,既不能将试验作为谋取地方或者部门特权或者利益的手段,也不能将试验作为拖延改革的策略。第二,行政改革试验及其授权必须具有妥当性,即拟进行的改革应当具有可试性,可以通过试验验证改革决策的科学性、可行性,可以在试验过程中积累经验,可以为全面推进改革创造条件;此外,试验单位的数量、试验区域的广度、试验期限的长度足以保证试验评估的客观性和科学性。第三,行政改革试验及其授权必须具有必要性,即改革试验及其授权不可缺少,如果缺少相关试验,改革的可行性不能保证,对于改革的统一认识无法达成;授权试验单位的数量、试验区域的广度、试验期限的长度足以实现试验的目的,但不能超过必要的限度。第四,行政改革试验及其授权应当具有经济性,为行政改革试验所投入的人力和物力等成本应当低于或者等于改革试验可能取得的收益,不能得不偿失。只有同时符合以上几个方面的要求,行政改革试验授权

① 参见田村悦一:《自由裁量及其界限》,第185页;周佑勇:《行政法基本原则》,武汉:武汉大学出版社,2005年,第206—207页;胡建淼:《行政法学》,北京:法律出版社,2015年,第51—53页。

② 参见 *Associated Provincial Picture Houses v. Wednesbury Corporation* [1948] 1 K.B. 223 (C.A.). 另参见杨登峰:《从合理原则走向统一的比例原则》,《中国法学》2016年第3期。

③ 参见哈特穆特·毛雷尔:《行政法学总论》,第238—239页;刘权:《目的正当性与比例原则的重构》,《中国法学》2014年第4期。

才具有正当性、合理性。

应该说，上述几方面的要求构成了行政改革试验授权不可逾越的法律界限。

结束语

至此，本文已经系统回答了前言部分提出的三个基础理论问题。总体观点是：行政改革试验授权是介于立法授权与行政授权之间的一种新型授权制度，具有独立的法律地位，不能与其他授权制度相混同。行政改革试验授权行为包含暂时调整或者暂停部分法律适用和将该决定授予特定试验主体实施两个方面的内容。其中，暂时调整或者暂停部分法律适用是法律施行力的中止和新试验法的制定的有机组合，不属于有些学者所主张的法律修改；将暂时调整或者暂停适用决定授予特定试验主体实施是类似于行政特许的立法特别授权。作为一种公权力的行使方式，行政改革试验授权应当遵循《决定》提出的程序要求，且不得逾越明确性原则以及其他制约和规范裁量权的法律原则设定的边界。

本文论述也明确了行政改革试验授权的主体和程序：改革试验触及哪个主体制定的法律，就由该主体授权；改革试验触及哪个层阶的法源，就按照该法源的简易程序进行授权。此外，还为实施、评价和监督改革试验授权行为提出了形式和内容要求。这使得行政改革试验授权法治有了理论和规范基础。不过，也必须意识到，行政改革试验是一个复杂而漫长的过程。授权仅仅解决了行政改革试验启动的合法性、正当性问题，仅仅为改革试验提供了入场券。换言之，授权制度仅仅实现了对行政改革试验的事前制约，但不能实现对行政改革试验的事中、事后制约。这种情况下，对于行政改革试验过程的法律规范和约束将是进一步要研究的问题。

〔责任编辑：李树民〕

power construction has not only inspired theories relating to types and concepts of right but also provided modern jurisprudence with an interpretation of second order construction of the concept of law, the legal system or legal order. Its theory of practice rests on the fact that it offers a micro-mechanism shared by all forms of governance.

(5) A Jurisprudential Analysis of Authorization for Experimental Administrative Reform *Yang Dengfeng* • 136 •

As a new form of authorization with independent legal status, the authorization of experimental administrative reform falls between legislative and administrative authorization. Decisions on authorization of experimental administrative reform have two aspects, viz., “the temporary adjustment or temporary suspension of the application of certain provisions of a law” and “authorizing a given experimenting body to implement this decision.” In essence, the former is the organic combination of two elements: suspending the implementation of a law and formulating a new experimental law; it does not belong under amendment of the law. The latter, on the other hand, is a special legislative authorization similar to administrative franchise. As a method of exercising public power, authorization for experimental administrative reform should follow the procedural requirements laid down in the Resolution of the Central Committee of the CPC on Certain Major Issues Concerning Comprehensively Advancing the Law-based Governance of China; it may not overstep the bounds of the forms of expression or substantive contents determined by the principles of the modern rule of law.

(6) The Late Qing and the May Fourth Movement: From Reforming Classical Chinese to Reforming the Vernacular *Hu Quanzhang and Guan Aihe* • 159 •

In the course of the changes that took place in Chinese literature from the late Qing to the May Fourth period, the transformation of the language paradigm was a milestone with critical ontological significance. In the late Qing, Liang Qichao's efforts to reform classical Chinese and bring the high-flown classical language down to common usage created a new written style that mixed the classical and the vernacular and joined Chinese and Western literary styles. The new style, with its intellectual tension and strong passions, catalyzed the reform of Chinese literature